

1501572-65.2020.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... visando à repressão ao crime de tráfico de drogas e, como havia denúncias anônimas antigas em relação ao bar do réu, os policiais militares optaram pela revista ao estabelecimento naquela data.

A testemunha PM Mauro foi clara ao afirmar que as denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas no bar do réu eram antigas e que, na ocasião da diligência, não havia qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

2ª Vara

Rua Dr. João Adolfo Stein, 171, Capivari - SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501572-65.2020.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501572-65.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ EDMAR DOS SANTOS LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Vistos.

JOSÉ EDMAR DOS SANTOS LOPES foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), porque, segundo narrou a denúncia, no dia 17/12/2020, por volta das 21h31min, na Rua Coronel Defino, 2, Centro, Capivari, o réu guardava, para fins de comercialização, um tijolo de maconha, pesando 634 gramas de massas líquida, substância esta entorpecente e que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 08/01/2021 (fls. 95/96) e recebida em 15/01/2021 (fls. 102/104).

Citado em 20/02/2021 (fls. 148), o réu apresentou sua resposta à acusação à fls. 120/142.

Realizada a audiência de instrução, foi ouvida a testemunha PM Mauro. Em continuação, foi ouvida a testemunha PM Natã. O réu foi interrogado.

Em seguida, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório. Passo a fundamentar.

De início, quanto à preliminar de inépcia da denúncia aventada por ocasião da resposta à acusação, a alegação defensiva não merece acolhida, pois a denúncia preencheu de forma razoável e adequada os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

De fato, o fato descrito na denúncia foi narrado com todas as circunstâncias necessárias e suficientes para o exercício pleno da defesa.

Por oportuna, é válida a transcrição da lição de Guilherme de Souza Nucci, em seu "Código Penal Comentado":

"Configura-se a inépcia da peça acusatória quando não se prestar aos fins aos quais se destina, vale dizer, não possuir a menor aptidão para concentrar, concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo ao réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Dentre outros fatores, são geradores de inépcia: a) a descrição de fatos de maneira truncada, lacunosa ou em desacordo com os dados constantes no inquérito; b) a inserção de coautores ou partícipes inexistentes na investigação policial; c) a narrativa tendente a firmar um determinado tipo penal, mas cuja conclusão aponta para outro (não se trata de mero erro de classificação); d) a menção a elemento subjetivo calcado em dolo, porém com descrição dos elementos componentes da culpa (e vice-versa); e) a introdução de jurisprudência ou referências doutrinárias (o réu se defende dos fatos alegados e não tem obrigação alguma de conhecer dados técnicos); f) a descrição muito extensa e detalhada do caso, de modo a tornar incompreensível o cerne da imputação; g) a descrição confusa e misturada de fatos típicos incriminadores diversos; h) qualquer descrição feita com estrangeirismo (exceção feita às consagradas fórmulas em latim, mesmo assim com a devida tradução)." (ed. Forense, 14ª ed., p. 869).

Como se nota, nenhuma das situações acima se verifica na denúncia, sendo certo que a petição inicial trouxe narrativa concisa e direta, com os elementos necessários à exata formulação da imputação, de modo a permitir, como foi de realizado exercido, o contraditório e a ampla defesa. Não há, portanto, que se reconhecer qualquer vício na denúncia, a macular o processo penal desde o seu nascedouro, de modo que fica rejeitada a preliminar lançada.

No mais, verifico que o processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Passo, pois, a conhecer diretamente do mérito.

A denúncia é improcedente.

A materialidade se encontra devidamente comprovada nos autos, conforme o auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudo de constatação de fl. 13 e laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 88/90.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos.

Ouvido em juízo como testemunha, o PM Mauro narrou, em breve síntese, que, na data dos fatos, foi realizada uma operação da Polícia Militar na cidade de Capivari, envolvendo a fiscalização de bares; que, como havia denúncias pretéritas envolvendo o bar de propriedade do réu no tráfico de drogas, optou pela fiscalização também de seu estabelecimento; que as denúncias eram anteriores ao da ocorrência e que, chegando ao bar, não havia nenhuma atividade suspeita no estabelecimento; que o bar estava em funcionamento e vendia bebidas, cigarros e alimentos; que havia clientes no bar consumindo bebida alcoólica e alimentos, bem como jogando algum jogo de mesa; que o estabelecimento foi vistoriado e, no interior de um congelador que se encontrava no interior do bar (isto é, no espaço reservado do bar e não aquele acessado pelo público), foi encontrada a droga apreendida; que se tratava de uma porção de maconha, a qual estava congelada e havia sinais de já ter sido picada (isto é, retiradas porções menores do pedaço maior); que nenhum cliente afirmou que estava no local para comprar drogas ou para consumir drogas no local; que o depoente já havia passado inúmeras vezes defronte ao bar e apenas viu pessoas consumindo bebidas alcoólicas e não realizou abordagem no estabelecimento anteriormente.

Ouvido em juízo como testemunha, o PM Natã informou que estava realizando operações de busca em bares; que foi realizada a revista ao local e, no interior do freezer foi encontrada uma porção de maconha; que era uma quantidade expressiva de maconha,

envolvida em uma sacola branca, tratando-se de um tijolo; que não se recorda de ter visto usuários de drogas no estabelecimento do denunciado; que a diligência no bar do réu foi realizada em razão de ter sido realizada operação na data em bares e havia denúncias anteriores sobre tráfico de drogas; que não sabe informar se tais denúncias eram reiteradas; que as pessoas foram abordadas e todos os clientes foram revistados; que com os clientes do bar, nada de ilícito foi localizado; que, no momento em que foi realizada a diligência, havia uma moça no estabelecimento e ela franqueou a entrada da equipe policial e autorizou as buscas.

Interrogado, o réu disse que os policiais chegaram ao bar; que o depoente estava no bar, jogando baralho; que sua esposa estava dentro do bar, atendendo a clientes; que os clientes foram retirados do bar e revistados; que os policiais ingressaram dentro do bar e o depoente não sabe dizer se a sua esposa autorizou ou não o ingresso dos policiais no bar; que além do bar o depoente tem um depósito de bebidas; que a droga era para o consumo próprio do depoente; que o depoente nunca vendeu drogas; que nunca vendeu drogas em seu bar; que o valor apreendido foi conseguido com o seu comércio.

Como se nota, é inequívoca a apreensão de drogas no interior do bar do réu. Ocorre que a diligência policial que levou à referida apreensão de drogas foi realizada de forma ilegal, sem mandado e sem que houvesse qualquer suspeita de flagrante delito. As testemunhas relataram em juízo que o estabelecimento foi vistoriado em uma operação geral na cidade, visando à repressão ao crime de tráfico de drogas e, como havia denúncias anônimas antigas em relação ao bar do réu, os policiais militares optaram pela revista ao estabelecimento naquela data.

A testemunha PM Mauro foi clara ao afirmar que as denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas no bar do réu eram antigas e que, na ocasião da diligência, não havia qualquer suspeita ou sequer indicio de atividade ilícita no local.

De fato, quando as testemunhas chegaram ao bar, conforme narrativa delas mesmas, seu funcionamento ocorria em perfeita normalidade: não havia sinais de uso de drogas no local, seja fora do bar ou em seu interior; tampouco havia movimentação típica de tráfico. Além disso, havia clientes no local, consumindo bebidas e comidas vendidas no estabelecimento.

Em suma, não havia a menor suspeita de que, no interior do estabelecimento comercial em questão, estava sendo praticado qualquer crime. Não havia fundada suspeita de flagrante delito.

Observo, neste ponto, que a parte do bar não acessível ao público é considerado domicílio, sujeito à proteção constituição de sua inviolabilidade, nos termos do art. 150, § 4º, inciso III, do Código Penal (§ 4º - A expressão "casa" compreende: III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.).

Nesse sentido, o STF, apreciando o tema 280 da repercussão geral (RE/603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes), por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados",

Logo, inexistentes fundadas razões, por consequência lógica, é inadmissível o ingresso forçado no domicílio.

Denúncia anônima, não é fundamento legítimo para a entrada forçada em domicílio.

Vale anotar que denúncia anônima sequer autoriza a instauração de inquérito policial, quanto mais de autorizar o ingresso em domicílio de qualquer indivíduo.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. FUGA ISOLADA DO SUSPEITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE PROVAS CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. No RE n.º 603.616/Tema 280/STF, a Suprema Corte asseverou que a flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente previstas (art. 5º, XI, da CF).

2. Apesar de se verificar precedentes desta Quinta Turma em sentido contrário, entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento que exige a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência"). 4. Recurso em habeas corpus provido para que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante na ação penal n.º 0006327-46.2015.8.26.0224, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL E SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Ainda que esta Sexta Turma tenha admitido como fundamento para a prisão preventiva a relevante quantidade entorpecentes apreendidos em poder da paciente, tratando-se de 132 pedras de crack, 84 papелotes de cocaína e ainda 26 trouxinhas de maconha, não foi apontado nenhum elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência da paciente, citando-se apenas a verificação de denúncias de tráfico de drogas que receberam através do "Disque Denúncia", e a fuga do adolescente. 2. Verifica-se ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, quando não há referência a prévia investigação policial para verificar a possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e robustas acerca da traficância no domicílio violado. 3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura da recorrente, TEREZA RODRIGUES, e de ofício determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001783-23.2016.8.26.0695. (RHC 83.501/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 05/04/2018) Como se nota, o entendimento de que o ingresso em domicílio fundado exclusivamente em denúncia anônima não é admissível foi adotado por ambas as Turmas do STJ, motivo pelo qual se pode afirmar que configura entendimento pacífico na Seção Criminal (isto é, Terceira Seção) do STJ.

No presente caso, entendo que houve conduta açodada dos policiais militares, que ingressaram em local protegido pela inviolabilidade do domicílio sem mandado e sem que houvesse indício ou a menor suspeita de flagrante delito em curso.

Caso se admita, neste caso, a validade da apreensão das drogas, estar-se-á justificando que o domicílio de qualquer cidadão seja motivo de devassa a partir de mera maledicência da vizinhança, bastando um telefonema anônimo para o 190 para que a residência seja vasculhada por policiais civis, militares ou guardas civis municipais.

Finalmente, destaco que a alegada autorização concedida para o ingresso dos policiais em local protegido pela inviolabilidade domiciliar não ficou comprovada. Acertadamente, o STJ, analisando a questão, definiu que tal autorização deve ser escrita. A

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SEM DENÚNCIA E SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESCRITO DO MORADOR. FUGA DE INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias

do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. O avistamento de um indivíduo correndo para o interior de uma residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência"). Precedentes. 4. Aliás, em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (...) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. E apresentou as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo, e preservada tal prova enquanto durar o processo. e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência. 5. No caso concreto, embora o acórdão impugnado faça alusão à afirmação dos policiais responsáveis pela busca domiciliar de que o paciente teria autorizado a entrada na residência, evidencia que agiram sem mandado judicial e sem o amparo de denúncia ou de investigação prévias que os conduzisse a crer que naquele local havia tráfico de drogas. Suas suspeitas tiveram por base apenas o fato de que uma pessoa que estava na frente da casa correu para o seu interior assim que percebeu a aproximação da viatura policial. 6. Deve ser considerada inválida eventual autorização do morador da residência vistoriada, se essa autorização não foi concedida por escrito, na esteira da tese firmada no HC 598.051 (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), tanto mais quando a descrição dos procedimentos efetuada pelos policiais, em sede inquisitorial, se revela inverossímil, ao afirmarem que, após baterem à porta da residência, quando finalmente abriu, o paciente teria consentido na busca. 7. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião, bem como as derivadas, devem ser consideradas ilícitas. 8. Habeas corpus não conhecida. Ordem concedida de ofício para reconhecer a nulidade da prova colhida na busca domiciliar, bem como das

provas derivadas, absolvendo o paciente das imputações de tráfico de drogas e corrupção ativa. (HC 686.489/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, pois não exigir autorização escrita ou bem comprovada por meio audiovisual tem o efeito de tornar inócua a proteção constitucional do domicílio, bastando que a autoridade violadora afirme, a posteriori, ter recebido consentimento do morador.

Destaco que a autorização é plenamente cabível de ser colhida, porquanto as polícias militar, civil e guardas civis realizam boletins de ocorrência e relatórios in loco diariamente, em toda e qualquer atuação, mesmo nas mais corriqueiras. A ausência de autorização escrita é indicativo de que não houve autorização e, faltando a autorização, ilícito foi o ingresso dos policiais militares no bar do denunciado.

Em suma, por entender inadmissível como prova a apreensão de drogas levada a cabo neste feito, entendo que a condenação do réu carece de outras provas, motivo pelo qual se impõe a sua absolvição.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o(s) réu(s) JOSÉ EDMAR DOS SANTOS LOPES pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Restitua-se o numerário apreendido ao acusado.

Expedição de certidão do Convênio OAB/DPE. Em caso de defesa patrocinada por meio do Convênio OAB/DPE, aguarde-se o decurso do prazo para interposição de recurso. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários (para pagamento de 100% do valor previsto na tabela). Na hipótese de interposição de recurso por qualquer uma das partes, expeça-se certidão de honorários, observando-se a seguinte regra do Convênio: "nos processos criminais de competência do Juízo singular, após a sentença condenatória ou absolutória com interposição de recurso por quaisquer das partes, 70% (setenta por cento) do valor previsto na tabela por ocasião da sentença e, os 30% (trinta por cento) restantes, após o trânsito em julgado do acórdão." Com o trânsito em julgado, procedam-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Capivari, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA